

1073759-83.2021.8.26.0053

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Gilsa Elena Rios

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 15ª Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... - Acusado do cometimento de associação e tráfico de drogas, com posterior absolvição por insuficiência de provas (art. 386, III e VII, do CPP) - Sentença de improcedência - Recurso do autor - Desprovemento de rigor - Responsabilidade Civil - Não configuração dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil do requerido - Ausência de provas suficientes a ensejar a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

15ª Vara da Fazenda Pública

Viaduto Dona Paulina,80, São Paulo - SP - cep 01501-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1073759-83.2021.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1073759-83.2021.8.26.0053

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

John Paulo Cominato dos Santos

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilsa Elena Rios

Vistos.

Trata-se de ação de indenização por danos morais, ajuizada por JOHN PAULO COMINATO DOS SANTOS em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Narra, em síntese, que foi processado criminalmente, acusado do delito de Peculato (art. 312, §1º do Código Penal) em ação penal que tramitou perante a 1ª Vara Judicial da Comarca de Novo Horizonte-SP sob o nº 0000854-82.2014.8.26.0396. A Sentença Condenatória transitou em julgado para a acusação no dia 14 de outubro de 2014. Alega que houve prescrição da pretensão punitiva, contudo a autoridade jurisdicional no dia 29 de janeiro de 2019 optou por indeferir o pedido de prescrição da pena, bem com determinou a conversão da pena restritiva na privativa de liberdade com aplicação imediata da pena no regime aberto, e ainda fixou a prestação de serviço a comunidade pelo mesmo prazo da condenação como uma das condições do regime aberto, sob pena de regressão. Após recurso, somente no dia 10 de março de 2020, após proferido o Acórdão que reconheceu o termo inicial de contagem de prazo prescricional é que o Juízo de primeira instância competente decidiu por suspender a punição imposta; e ao final, no dia 23 de junho de 2021 é que se reconheceu a extinção da pretensão executória da pena, para a expedição do Alvará de Soltura no dia 01 de julho de 2021. Afirma que permaneceu ilegalmente privado de parte de sua liberdade de locomoção desde o dia, em virtude de pena corpórea já sabidamente prescrita; além de ter prestado meses de serviço comunitário gratuitamente, o que

enseja na condenação do Estado no pagamento de indenização por danos morais.

Citada a FESP apresentou contestação de fls. 128/142. Alega ausência de responsabilidade civil do Estado, ante a ausência de nexo de causalidade. Afirma que não houve prisão ilegal ou privação de liberdade, pois as decisões judiciais foram fundamentadas. Argui que na data da prisão do autor, não existia qualquer decisão judicial que havia reconhecido a prescrição da pretensão punitiva estatal e sendo reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, o autor foi imediatamente colocado em liberdade. Por conseguinte, não houve erro judiciário apto a justificar a imputação de responsabilidade civil à Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Logo, não há que se falar que o autor cumpriu pena no regime aberto ilegalmente. Impugna o valor postulado a título de indenização por dano moral. Ao final requer a improcedência.

Réplica nas fls. 153/155. As partes não postularam produção de prova.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

As questões de mérito a serem apreciadas são exclusivamente de direito, tornando desnecessária a produção de provas em audiência, razão pela qual promovo o julgamento antecipado integral do mérito, com fundamento no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil.

A presente demanda circunscreve-se à análise, em resumo, de eventuais danos morais sofridos pelo autor em decorrência da sua manutenção no cárcere, em prisão pena, tendo sido reconhecida posteriormente causa extintiva da punibilidade (prescrição), já ocorrida quando da determinação do cumprimento da sanção penal.

Sob o enfoque jurídico, a responsabilidade civil do estado sempre foi objeto de grande discussão.

Em escorço histórico, num primeiro momento tinha-se a ideia de que ao estado não era imputada qualquer responsabilidade por atos praticados pelos seus agentes, o que se traduzia na frase francesa le roi le peut mal faire (o rei não pode fazer mal).

Em seguida, à responsabilidade estatal foi trazido o conceito de culpa, transferindo a necessidade de prova pelo prejudicado da prática, por parte do estado, de atos de gestão – atos praticados pelo estado sob o regime jurídico privado e sobre os quais o estado teria responsabilidade – ou de atos de império – cujo regime jurídico era o de direito público e, como o estado não errava, seria portanto por eles irresponsável. Em progressão, a culpa administrativa aparece, revelando que bastaria a prova pelo prejudicado da falta do serviço público para a caracterização da responsabilidade, demonstrando que o serviço não foi prestado, que o foi de forma insuficiente ou que foi prestado com atraso, situações nas quais estaria presumida a culpa estatal, surgindo a obrigação em indenizar. Sem abandonar esse conceito, surge também a responsabilidade pelo risco administrativo, em que o elemento subjetivo desaparece (dolo ou culpa), o que faz surgir, assim, a denominada responsabilização objetiva.

O direito brasileiro, majoritariamente, aplica aos casos de omissão estatal a teoria da culpa administrativa, e nos casos de comissão, a teoria do risco administrativo, o que se extrai do artigo 37, parágrafo 6.º da Constituição da República Federativa do Brasil, que assim prevê:

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...) § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Conclui-se, assim, pela aplicação da teoria do risco administrativo ao caso concreto tratado neste processo, o que estabelece a necessidade de prova, por parte

do autor, além da conduta perpetrada, do nexo de causalidade e do dano efetivamente causado, orbitais a partir dos quais o deslinde do feito seguirá a sua conclusão. É entendimento jurisprudencial dominante aquele segundo o qual, dadas as condições processuais enfrentadas pelos agentes públicos ao tempo da persecução penal, a prisão cautelar ou a submissão do réu ao processo criminal não conferem direito à indenização por abalo moral, eis que caracterizado o exercício do cumprimento de dever legal por parte dos atores da justiça criminal.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais embasada em prisão em flagrante, supostamente ilegal. Inquérito policial posteriormente arquivado, por falta de provas. Fato que não induz reparação, diante da ausência de abuso de poder ou de quaisquer outras ilegalidades - Circunstâncias verificadas na ocasião que mereciam elucidação e autorizavam a voz de prisão - Estrito cumprimento do dever legal. Ação julgada improcedente. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1004650-41.2021.8.26.0292; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/03/2022; Data de Registro: 29/03/2022);

Apelação Cível - Indenização por danos morais - Policial civil preso cautelarmente - Acusado do cometimento de associação e tráfico de drogas, com posterior absolvição por insuficiência de provas (art. 386, III e VII, do CPP) - Sentença de improcedência - Recurso do autor - Desprovisionamento de rigor - Responsabilidade Civil - Não configuração dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil do requerido - Ausência de provas suficientes a ensejar a responsabilização - Ausência de ilicitude na conduta das autoridades - Exercício regular de direito, ante os elementos de que dispunham para a iniciativa - Irrelevância do desfecho da ação penal - Precedentes - Carência de prova suficiente de danos que mereçam indenização - Não vinga a pretensão reparatoria - Improcedência que se impunha - Honorários advocatícios majorados na forma do art. 85, § 11º, do CPC em razão dos trabalhos adicionais em sede recursal, observada a gratuidade de Justiça concedida ao autor - R. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1015424-47.2016.8.26.0053; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/03/2022; Data de Registro: 16/03/2022);

APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - DANOS MORAIS - Pretensão à reparação civil por suposto erro judiciário - Impossibilidade - Autor preso provisoriamente com ulterior sentença de rejeição da denúncia - Atuação estatal consubstanciada em estrito cumprimento do dever legal - Responsabilização do Estado por erro judiciário que exige a existência de ilegalidade ou abuso na persecução criminal por parte dos agentes públicos - Não configuração no caso concreto - Precedentes - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1049495-02.2021.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/03/2022; Data de Registro: 14/03/2022).

No caso dos autos, o MM. Juiz que analisou o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória assim fundamentou o seu indeferimento:

(...)

2. Pretende o reeducando a declaração de prescrição da pretensão executória, uma vez que o Ministério Público não recorreu da sentença condenatória, o que gerou o trânsito em julgado para a acusação no dia 14/10/2014, ou seja, há mais de quatro anos do início da execução da pena.

O Ministério Público pugnou pelo indeferimento, sob o argumento de que o reeducando se valeu da interposição de vários recursos que sequer foram conhecidos, e que não seria possível concretamente a execução da pena quando do trânsito em julgado para a acusação.

Observa-se dos autos que, de fato, o trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu no dia 14/10/2014. Porém, o reeducando interpôs recurso contra a sentença condenatória, sendo que o acórdão deu parcial provimento apenas para diminuir o valor da prestação pecuniária. Foram interpostos embargos de declaração, os quais

foram rejeitados. Ademais, foi interposto Recurso Especial (o qual não foi admitido), Agravo em Recurso especial (o qual não foi conhecido), Agravo Regimental (também não conhecido), embargos de declaração em Agravo Regimental (não conhecidos), Recursos extraordinário (negado seguimento), e Agravo Regimental (não conhecido).

Pois bem. É cediço que à época da sentença proferida pelo juízo a quo, e quando do acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça, prevalecia o entendimento de que não poderia haver a execução provisória da pena, sob pena de infringência do princípio da presunção de inocência.

Tal entendimento baseava-se no fato da Lei Maior prever que ninguém poderá ser considerado culpado até que haja o trânsito em julgado da sentença penal condenatória (art. 5º, LVII). Por força desse princípio, prevaleceu no STF o entendimento de que não existia no Brasil a execução provisória da pena. Assim, enquanto pendente de julgamento os recursos interpostos pela defesa, o condenado não poderia iniciar o cumprimento da pena.

E se o entendimento era da impossibilidade de execução provisória da pena, o órgão estatal não tinha a possibilidade de cumprir o seu poder-dever de punir o infrator. Por isso, o artigo 112, inciso I, do Código Penal, não pode ser interpretado literalmente, sob pena de afrontar o ordenamento jurídico e a própria Carta Magna. Evidente que a prescrição da pretensão executória (quando o Estado perde o seu poder-dever de executar uma sanção penal já definitivamente imposta pelo Poder Judiciário em razão de não ter agido nos prazos previstos em lei) não pode ter seu início antes da possibilidade de iniciar a possibilidade de exercício do poder dever estatal, sob pena de reduzir/aniquilar o poder punitivo, e beneficiar os condenados que se utilizarem de todos os infundáveis recursos previstos na legislação brasileira.

In casu, não precisa de maiores elucubrações para se chegar a conclusão de que o reeducando exauriu todos os recursos possíveis e previstos em Lei com o fim procrastinar o feito e beneficiar-se da prescrição.

Contudo, tal prática não pode servir de escudo contra o poder punitivo estatal, sob pena de gerar insegurança jurídica e uma sensação geral de impunidade, especialmente nos crimes com penas menos elevadas.

Portanto, se o princípio da presunção da inocência consistia num óbice, à época, à possibilidade de execução provisória da pena, o lapso temporal da PPE deve ter início quando possível a execução da pena, pois não se pode prescrever aquilo que não pode ser executado.

Nesse sentido o entendimento esposado pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

2. A partir do julgamento pelo Plenário desta Corte do HC nº 84.078, deixou-se de se admitir a execução provisória da pena, na pendência do RE. 3. O princípio da presunção de inocência ou da não-culpabilidade, tal como interpretado pelo STF, deve repercutir no marco inicial da contagem da prescrição da pretensão executória, originariamente regulado pelo art. 112, I do Código Penal. 4. Como consequência das premissas estabelecidas, o início da contagem do prazo de prescrição somente se dá quando a pretensão executória pode ser exercida. (...) (STF. 1ª Turma. HC 107710 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 09/06/2015).

No caso vertente, o reeducando foi condenado a pena privativa de liberdade no patamar de 02 (dois) anos, sendo assim, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal. Considerando que a execução da pena foi possível a partir de 02/04/2018, tem-se pela inoccorrência da prescrição.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido da Defesa. (fls. 37/39)

Por sua vez, assim entendeu o E. Tribunal de Justiça:

(...) O recurso merece parcial acolhida.

Segundo consta, nos autos da referida ação penal, o agravante foi condenado às penas de dois anos de reclusão (substituída por duas restritivas de direitos) e dez dias-multa, por infração ao artigo 312, § 1º, do Código Penal.

O prazo extintivo, no caso, é de quatro anos, e deve ser regulado consoante interpretação literal do artigo 112, inciso I, do Código Penal, ou seja, com o

termo inicial de contagem a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória para a Acusação (no caso, em 14 de outubro de 2014 fls. 15). Não se ignoram precedentes no sentido de que esse termo inicial se daria somente com o trânsito em julgado para ambas as partes (Acusação e Defesa). Porém, não há interpretação extensiva, em detrimento do agente, de norma penal material que, de qualquer forma, o favoreça. Finalmente, não se conhece da situação processual do agravante o recurso não se acha devidamente instruído nesse aspecto e em razão disso não se mostra possível reconhecer-se desde logo a prescrição executória, o que deve ser feito em primeiro grau, à luz de maiores informações a respeito.

Posto isso, meu voto dá parcial provimento ao recurso para que a prescrição executória seja contada a partir da data do trânsito em julgado para o Ministério Público (fls. 75/76).

O que se extrai dos entendimentos expostos nas decisões acima colacionadas é que os fundamentos a partir dos quais o MM. Juiz indeferiu o pedido de extinção da punibilidade se calcavam em cizânia jurisprudencial de alta instabilidade.

Bem por isso é que o E. Desembargador, em seu voto, afirmou que não se ignoram precedentes no sentido de que esse termo inicial se daria somente com o trânsito em julgado para ambas as partes (Acusação e Defesa), o que dá a tônica da divergência doutrinária e jurisprudencial a respeito do tema.

Não se pode, diante disso, imputar a eventual falha na prestação jurisdicional a questão jurídica cuja conclusão, embora tenha revelado prejuízo ao autor, se deu no estrito cumprimento do convencimento motivado do magistrado em relação ao ordenamento jurídico então vigente.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Sucumbente, arcará o autor com eventuais custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade prevista no artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo Civil.

P. I. C.

São Paulo, 02 de maio de 2022.

GILSA ELENA RIOS

Juiza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.